

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 30/04/2025
MEDIDA CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC 001078.989.25-8.

Representante: Extra Mais Alimentos Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

Responsáveis: Lúcio do Carmo da Silva - Diretor do Departamento de Licitações e Contratos e Subscritor do edital; Luciana de Oliveira Ferreira - Secretária Municipal de Educação; Ricardo Alberto Pereira Piorino – Prefeito.

Assunto: Representação contra o edital do Pregão eletrônico – Registro de Preços nº 189/2024, processo administrativo nº 21303/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba objetivando a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e especiais, incluindo produtos para alunos com necessidades nutricionais especiais e produtos para atender ao cardápio da Alimentação Escolar de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital.

Valor estimado: R\$ 9.026.908,00 (nove milhões, vinte e seis mil, novecentos e oito reais).

Procurador do Ministério Público de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogado habilitado no e-tcesp: Anderson Plinio da Silva Alves (OAB/SP 351.449).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARECER JURÍDICO. DESATENÇÃO AO INCISO II DO §1º DO ARTIGO 53 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. RECOMENDAÇÕES DE AJUSTAMENTO. DESATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO RELATOR. INCIDÊNCIA DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 104, INCISOS III E V DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 709, DE 14 DE JANEIRO DE 1993 E DO ARTIGO 219-E, INCISO I DO REGIMENTO INTERNO DO TCESP. USO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA OBJETO MENSURÁVEL ATRAVÉS DE ADEQUADO PLANEJAMENTO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA EVENTUALIDADE DO FORNECIMENTO E IMPREVISIBILIDADE DA DEMANDA. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. REQUISIÇÕES DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO COMPETENTE. ILEGAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 69, II DA LEI 14.133/21. EXAME DE AMOSTRAS DESPROVIDO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE. IRREGULAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, §3º DA LEI Nº 14.133/21. AUSÊNCIA DE

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO FORNECEDOR NA HIPÓTESE DE EVENTUAL ATRASO NOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONFIRMADA. DESATENÇÃO AO COMANDO DO ARTIGO 25, CAPUT C/C O ARTIGO 92, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. CORREÇÕES DETERMINADAS. ADMISSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL EM PREGÃO ELETRÔNICO. AMPARO NO §4º DO ARTIGO 17 DA LEI 14.133/21. REQUISIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. ADMISSÍVEL. PREVISÃO NO ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. REQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA SANITÁRIA DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALIMENTOS. JUSTIFICÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RECOMENDAÇÃO.

1. A ausência de parecer jurídico elaborado nos termos do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21 expõe deficiência da fase preparatória do procedimento licitatório e fragilidade das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade no âmbito da segunda linha de defesa, tal como definida pela nova Lei de Licitações e Contratos.
2. Uma vez ausentes os pressupostos da eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda, não se admite, com base apenas na necessidade de entregas semanais, a compra no sistema de registro de preços de gêneros alimentícios estocáveis e destinados a suprir necessidade permanente na elaboração cotidiana da merenda escolar e em quantidades absolutamente mensuráveis através de adequado planejamento;
3. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021;
4. Em procedimentos licitatórios regidos pela Lei Federal nº 14.133/21, não se admite a exigência de Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e de Plano de Recuperação acolhido ou homologado como requisito de qualificação econômico-financeira, dada a falta de amparo na norma do artigo 69, inciso II da Lei 14.133/21;
5. É obrigatória a definição no edital de critério de atualização monetária ou compensação financeira ao fornecedor na hipótese de eventual atraso nos pagamentos devidos pela Administração, nos termos do artigo 25, caput c/c o artigo 92, inciso V, da Lei federal nº 14.133/21;
6. Tratando-se de certames licitatórios promovidos na forma eletrônica, admissível o recebimento de impugnações exclusivamente por meios eletrônicos, consoante autoriza o §4º do artigo 17 da Lei federal nº 14.133/21.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **EXTRA MAIS ALIMENTOS LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico – Registro de Preços nº 189/2024, processo administrativo nº 21303/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA** objetivando a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e especiais, incluindo produtos para alunos com necessidades nutricionais especiais e produtos para atender ao cardápio da Alimentação Escolar de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital.

1.2. A Representante aponta as seguintes insurgências contra o ato convocatório:

1.2.1. O Item-6. DA PROPOSTA DE PREÇOS, subitens 6.1, 6.4 e 8.4 c.c. 8.4.1, condiciona a aceitabilidade da proposta comercial à inserção da ficha técnica (emitida pelos fabricantes) de cada produto do respectivo lote (mais de 60 itens), sob pena de desclassificação;

Acrescenta haver contradição no edital que, num primeiro estágio, condiciona a aceitabilidade da proposta com a inserção da ficha técnica, mas, posteriormente, concede prazo de 10 dias para a licitante apresentar amostras e demais documentos técnicos;

E reclama da prerrogativa potestativa do pregoeiro em admitir ou não a proposta desacompanhada da ficha técnica a pretexto de previsão editalícia vinculante as partes.

1.2.2. Pesquisa de preços em descompasso com os preços atuais de mercado, encontrando-se com valores defasados;

1.2.3. Exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial como requisito de qualificação econômico-financeira, em desacordo com o artigo 69, inciso II da Lei 14.133/21;

1.2.4. Requisição de amostras sem a previsão de critérios objetivos de avaliação;

1.2.5. Omissão do edital quanto a definição de critério de atualização monetária na hipótese de atraso no pagamento, em desatenção ao disposto no artigo 92, inciso V, da Lei 14.133/21;

1.2.6. Admissibilidade de impugnações ao edital exclusivamente por meio de plataforma digital;

1.2.7. O item 9.9.4.1 exige Alvará ou Certificado de Vigilância Sanitária c.c Certificado de Vistoria Sanitária dos Veículos, contrariando a Lei Federal nº 13.874/2019, que dispensou a obrigatoriedade de Licença de Funcionamento para empresas que exercem atividade de baixo risco à saúde e também em desacordo com a Portaria nº CVS nº 01/2019, que dispensou as empresas enquadradas no agrupamento 11 – Comércio Atacadista de Alimentos, de sujeitar-se à Licença de Funcionamento, por considerá-las como de complexidade baixa.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As críticas do Representante que incidiram sobre i) requisição de fichas técnicas como condição de aceitabilidade das propostas, a critério do pregoeiro; ii) exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial como requisito de qualificação econômico-financeira; iii) requisição de amostras sem a previsão de critérios objetivos de avaliação, evidenciaram presença de indícios de desatenção ao preceito do artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”; artigo 11, incisos I e II; artigo 69, inciso II, além de desatenção ao

princípio do julgamento objetivo, previsto no artigo 5º, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

1.5. Além das questões impugnadas na representação, identifiquei na apreciação preliminar a presença de outros temas de destacada importância e que igualmente demandavam justificativas e esclarecimentos da Municipalidade Representada:

1.5.1. A primeira questão consiste na adoção do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e especiais para atender ao cardápio da Alimentação Escolar.

1.5.2. O segundo ponto incide sobre a necessidade de **demonstração da legalidade da exigência de atestados de fornecimentos anteriores como requisito de qualificação técnica das proponentes**, nos termos do item 9.9.4 do edital¹.

Neste panorama, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 27/01/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos.

¹ **9.9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

a) Atestados passados por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que comprovem que a respectiva licitante executou ou executa, a contento, fornecimento de natureza e vulto similares ao desta licitação, na proporção de no mínimo 50% do objeto licitado, conforme sumula 24 do TCE, sendo permitida a soma de atestados.

b) É permitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado, conforme artigo 15, inciso III da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações.

Requisitei, por oportuno, que a Municipalidade apresentasse as manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo **órgão de assessoramento jurídico da Administração**, no exercício do **controle prévio de legalidade da contratação**, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, visando a demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao **exame específico das cláusulas editalícias e condições de contratação impugnadas na Representação e dos demais aspectos questionados de ofício por este Relator**.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 05/02/2025.

1.5. Notificada, a Municipalidade colacionou aos autos **na data de 10/02/2025** (evento 35) a documentação requisitada por este Relator, em atendimento ao artigo 171, §2º da Lei federal nº 14.133/21.

1.6. A **Assessoria Técnico-Jurídica** se manifestou pela **procedência parcial** da representação (evento 47).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 52) emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da representação e dos pontos suscitados de ofício na decisão cautelar, com a consequente anulação do certame, por uso inadequado do Sistema de Registro de Preços, propondo recomendações.

Além disso, propôs a aplicação de multa prevista no artigo 104, inciso III, da Lei Complementar Estadual 709/199319 e no artigo 219-E, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em função do descumprimento da determinação para que fosse juntada manifestação do órgão de assessoramento jurídico municipal no exercício do controle de legalidade prévio.



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
DIMAS RAMALHO
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 30/04/2025
MEDIDA CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

TC-001078/989/25-8

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **EXTRA MAIS ALIMENTOS LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico – Registro de Preços nº 189/2024, processo administrativo nº 21303/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA** objetivando a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e especiais, incluindo produtos para alunos com necessidades nutricionais especiais e produtos para atender ao cardápio da Alimentação Escolar de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital.

2.2. Começo por um aspecto que considero fundamental em relação à fase preparatória do certame e aos instrumentos de controle das contratações, de acordo com a disciplina da Lei Federal nº 14.133/21.

Ao deferir a medida cautelar de suspensão do procedimento impugnado, requisitei que fossem trazidos aos autos as manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo **órgão de assessoramento jurídico da Administração**, no exercício do **controle prévio de legalidade da contratação**, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, visando a demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao **exame específico das cláusulas editalícias e condições de contratação impugnadas na Representação e dos demais aspectos questionados de ofício por este Relator.**

A Municipalidade Representada não apresentou o documento em questão.

O arquivo 04 do evento 35 é um parecer datado de 07 de fevereiro de 2025 que contesta parte das insurgências da própria representação. À toda evidência, o documento em questão não foi produzido na fase preparatória do certame pelo **órgão de assessoramento jurídico da Administração**, no exercício do **controle prévio de legalidade da contratação**, na forma do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21.

A omissão da Municipalidade implica na falta de demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao **exame específico das cláusulas editalícias e condições de contratação antes da divulgação do ato convocatório, configurando desatenção a um fator** fundamental em relação à fase preparatória do certame e aos instrumentos de controle das contratações, de acordo com a disciplina da Lei Federal nº 14.133/21.

Alerto a Municipalidade Representada que o parecer jurídico eventualmente elaborado sem o preenchimento de todos os seus requisitos legais, notadamente, sem a detalhada *“apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação”*, expõe, em tese, deficiência da fase preparatória do certame e possível fragilidade do controle preventivo de legalidade, de incumbência da segunda linha de defesa, tal como estruturada no artigo 169 da Lei 14.133/21².

² Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

§ 1º Na forma de regulamentação, a implementação das práticas a que se refere o **caput** deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em

Nesta fase de assimilação das novas regras gerais de licitação, considero prudente apresentarmos um panorama comparativo sobre as mudanças verificadas com o advento da Lei 14.133/21 em relação ao papel fundamental do órgão de assessoramento jurídico da Administração no âmbito da fase preparatória do certame e das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade.

A revogada Lei 8.666/93 dispunha:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

[...]

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

[...]

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

§ 2º Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#), e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do **caput** deste artigo observarão o seguinte:

I - quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

II - quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 assim disciplina a atuação da assessoria jurídica da Administração:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no [art. 54](#).

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

A nova lei de licitações e contratos, especialmente no inciso II do §1º deste artigo 53, trouxe importantes avanços ao detalhar mais a forma e conteúdo do parecer jurídico, passando a impor o uso de *“linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica”*.

Importante destacar que o artigo 169, inciso II, da Lei 14.133/21, ao posicionar o órgão de assessoramento jurídico da Administração na **segunda linha de defesa do controle das contratações**, atribuiu ao parecer jurídico uma inovadora **função fiscalizatória** com o objetivo de promover um controle preventivo de legalidade e regularidade da atuação administrativa. Faz parte desta atribuição a identificação de possíveis violações efetivas ou potenciais ao ordenamento jurídico e a propositura de medidas saneadoras ou de invalidação dos atos praticados visando a rigorosa observância da lei.

Registro que todas as linhas de defesa do controle de contratações estão subordinadas à observância dos critérios de ***oportunidade, materialidade, relevância e risco*** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, nos exatos termos do artigo 170 da Lei Federal nº 14.133/21.

Pelo exposto, **RECOMENDO** que a Municipalidade garanta nos seus procedimentos de contratação **atendimento suficiente ao comando do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei 14.133/21** quanto à estruturação e funcionamento da primeira e segunda linhas de defesa do controle de contratações, especialmente em relação ao **controle prévio de legalidade** a cargo do órgão de assessoramento jurídico da Administração, disciplinado nos artigos 53 e 169 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

2.3. As justificativas da Municipalidade não lograram demonstrar, no presente caso, a adequação do sistema de registro de preços para a compra de gêneros alimentícios estocáveis, pois a elaboração semanal do cardápio de merenda escolar não obsta a formulação de um planejamento de consumo para todo o ano letivo, de acordo com a estimativa de consumo individual, extraída da previsão do número total de discentes e da consulta a outros órgãos administrativos com perfil, necessidades ou demandas semelhantes, prevendo a entrega dos gêneros alimentícios de forma parcelada, como bem ponderou o Ministério Público de Contas em seu parecer.

O próprio Termo de Referência – Anexo II, em seu item 5, trata de justificar a adoção do sistema de registro de preços **unicamente em função da necessidade de entregas parcelas e da possibilidade de inauguração de unidades escolares**, nos seguintes termos:

“Justifica-se a aquisição por meio de Registro de Preço, visto que as entregas pontuais nas escolas seguem periodicidade semanal, devido ao espaço para armazenamento no estoque das unidades, além da possibilidade de inauguração de novas Unidades Escolares.”

Necessidade de entregas parcelas e possibilidade de inauguração de novas escolas são justificativas que nossa jurisprudência não recepciona para legitimar, por si só, a adoção do sistema de registro de preços.

A alegação da defesa de *“indeterminação do período e da quantidade dos insumos futuramente fornecidos”*, além de contrariar o próprio Termo de Referência que fala em entregas semanais, também não tem sustentação e não se coaduna com as práticas elementares que envolvem o planejamento e a gestão eficiente das políticas públicas.

Além disso, pondero que a utilização do Registro de Preços é admissível apenas em situações de incerteza da demanda, seja em relação a sua ocorrência, seja quanto à quantidade dos bens a ser adquirida, não se prestando tal sistemática à aquisição de objetos passíveis de quantificação e entrega em período certo e/ou previsível, conforme orientação inclusive consignada em Manual de orientação editado por esse E. Tribunal³.

³ Manual Licitações e Contratos: Principais aspectos da fase preparatória e gestão contratual. Publicação em 09/01/2020. Disponível em <https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/licitacoes-e-contratos-principais-aspectos-fase-preparatoria-e-gestao-contratual>

E, para eventuais oscilações nesses quantitativos, a lei reserva, dentro de limites, a possibilidade de supressões ou acréscimos nos fornecimentos, na forma do artigo 125 da Lei 14.133/21.

A eventualidade dos fornecimentos e a imprevisibilidade da demanda, características típicas do sistema de registro de preços, não se compatibilizam com as práticas e necessidades que envolvem a compra de insumos para merenda escolar como os que a Municipalidade pretende adquirir, quais sejam: **grãos, cereais e farináceos; massas alimentícias; pães e biscoitos; óleos, conservas e condimentos; itens matinais e outros gêneros não perecíveis.**

Como se vê, são **produtos básicos e disponíveis o tempo todo** no mercado, **não sujeitos à sazonalidade**, destinados a suprir necessidade permanente na elaboração cotidiana da merenda escolar e em quantidade absolutamente mensurável através de adequado planejamento.

Oportuna a transcrição do seguinte trecho do parecer do D. Ministério Público de Contas, contido no evento 52:

“Outro ponto a ser considerado é que a certeza de aquisição tende a atrair maior número de interessados, proporcionando aumento da competitividade e redução do valor das propostas. Já a voluntariedade na contratação do objeto, aspecto inerente ao registro de preços, desestimula a participação na disputa e, não raro, ocasiona a apresentação de preços incompatíveis com a extensão do compromisso assumido e com o prazo de validade da ata, por conta da possibilidade de venda em quantitativo abaixo do esperado ou da dúvida a respeito do momento em que será exigido o objeto ou de que forma, prejudicando eventuais ganhos em escala.”

Os produtos pretendidos mostram-se como passíveis de quantificação e entrega em período certo ou previsível, não restando demonstrada a ocorrência dos pressupostos legais do sistema de registro de

preços, a saber, eventualidade do fornecimento e a imprevisibilidade da demanda.

A utilização do sistema tradicional de licitação resultará no aumento da competitividade, bem como, por consequência, da vantajosidade, considerando a redução dos valores ofertados derivados da compra em escala e não do registro de compra em ata.

Uma das consequências do registro de preços é o incremento dos preços oferecidos, justamente em razão das incertezas envolvendo a prestação, resultando em uma contratação mais onerosa do que o necessário para a Administração”, vulnerando o atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e vantajosidade.

Neste sentido, as decisões dos TCs 14393.989.24-9 e 1250.989.24-1.

Portanto, a adoção irregular do sistema de registro de preços configura vício de origem que determina a necessidade de anulação do certame e do edital respectivo, na forma do artigo 71, inciso III da Lei nº14.133/2021, com vistas a permitir o retorno à fase preparatória e a reestruturação da estratégia de compra no sistema convencional.

2.4. Antes de ingressar no exame das insurgências da Representante, abordo o tema da **requisição de atestados de capacidade técnica em licitações destinadas ao fornecimento de bens**, questionamento de ofício que agreguei à decisão que deferiu a medida cautelar de suspensão do certame, proferida em 23/01/2025.

Muito embora minha posição sobre o tema ainda identifique, com todo respeito às posições contrárias, vedação legal a esta exigência em função da redação atribuída ao *caput* do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21, notadamente quanto ao segmento que, com absoluta clareza, dispõe que “a

documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a ...”, em prestígio ao **princípio da colegialidade** e à recente deliberação tomada por este Tribunal Pleno naquela oportunidade, meu voto acolhe os pronunciamentos da Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas para afastar o questionamento de ofício e autorizar a manutenção da exigência de atestados de capacidade técnica na forma como discricionariamente definiu a Administração no presente caso.

E passo ao exame das insurgências da Representante.

2.5. Começo pela questão alusiva à requisição de *“Ficha Técnica emitida pelo fabricante ou produtor, conforme aplicável, contendo descrição do produto, marca, ingredientes, modo de preparo quando houver, embalagem, rotulagem, composição nutricional e validade de todos os itens”*.

O Departamento Administrativo e Financeiro da Prefeitura, através da Divisão de Merenda responsável, por decisão conjunta já emitiu ordem da exclusão da regra que condiciona a aceitabilidade da proposta comercial à inserção da ficha técnica emitida pelos fabricantes de cada produto do respectivo lote (mais de 60 itens), sob pena de desclassificação.

Ainda que se trate de matéria, portanto incontroversa, trago novamente trecho de interesse do julgamento do TC-017589.989.21-9, em Sessão Plenária de 29/09/2021, sob minha relatoria:

Em que pese a indispensável preocupação da Prefeitura com a segurança alimentar dos alunos da rede municipal, os argumentos da defesa, calcados na importância das informações sobre os gêneros alimentícios, não são capazes de desconstituir o caráter restritivo da imposição.

A Origem deverá avaliar outras soluções viáveis para confirmar a legitimidade e confiabilidade das características organolépticas, composição nutricional e outras informações dos produtos que serão relevantes para a análise de conformidade dos itens ofertados com os requisitos mínimos de qualidade previstos no ato convocatório.

A imposição de entrega da Ficha técnica do produto, emitida pelo seu fabricante, devidamente assinada pelo técnico responsável, mesmo que dirigida somente ao vencedor, prejudica os fornecedores varejistas, distribuidores e não produtores, que deverão diligenciar perante os fabricantes dos produtos licitados, sem qualquer garantia de sucesso, para obtenção destes documentos, ficando claro que são pertencentes a terceiros alheios à disputa.

Destaco que esta imposição de assinatura do responsável técnico nas fichas técnicas dos produtos configura requisição de compromisso de terceiro alheio à disputa, em afronta à Súmula n.º 15 deste E. Tribunal.

A exigência cria desarrazoado ônus e desestímulo à participação no certame, expondo o pressuposto da ampla competitividade e delimitando as possibilidades de obtenção da proposta mais vantajosa.

Como se trata de cláusula impugnada que já foi objeto de ordem de exclusão do ato convocatório pela própria Administração, limito-me, neste ponto, a confirmar a procedência da reclamação da Autora.

2.6. A insurgência que aponta que a pesquisa de preços desenvolvida na fase preparatória do certame se encontra em descompasso com os preços atuais de mercado e com valores defasados foi objeto de impugnação administrativa acolhida pela Administração.

A instrução processual sobre a questão se mostrou prejudicada pois o Estudo Técnico Preliminar (ETP), especificamente em seu item 6 – Estimativa do Valor da Contratação, bem como o item 12 do Anexo II – Termo de Referência, menciona apenas a informação da estimativa de valor no montante de R\$ 9.026.908,00, bem como o indicativo da origem do orçamento estimativo (consultadas diversas fontes de pesquisa, incluindo órgãos públicos e preços de mercado), sem contudo, o detalhamento dos preços unitários referenciais, a demonstração das memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte.

De todo modo, como se trata de matéria incontroversa que a Representada acolheu em sede de impugnação administrativa, ratifico a procedência da queixa com determinação de que a Municipalidade garanta o pleno atendimento ao comando do artigo 18, §1º, inciso VI e artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/21.

2.7. Nossa jurisprudência vem consolidando o entendimento de que a exigência de Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e de Plano de Recuperação acolhido ou homologado excede as previsões do artigo 69, inciso II⁴ da Lei 14.133/21.

A requisição contida nos itens 4.4.4⁵ e 9.9.3, “a” e “a.1”⁶ deverá ser excluída do edital, dada a falta de fundamento legal.

Destaco que o caput do artigo 69 da Nova Lei de Licitações e Contratos dispõe que a avaliação da habilitação econômico-financeira “**será restrita à apresentação da seguinte documentação ...**” e algumas das requisições dos nos itens 4.4.4 e 9.9.3, “a” e “a.1 do edital não estão contempladas no referido dispositivo legal.

⁴ Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
[...]

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

⁵ **4.4.4.** Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em recuperação judicial, desde que apresente, na fase de habilitação, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

⁶ **9.9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) Certidão negativa de falência ou concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da licitante

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

Memoro que sob a vigência da Lei 8.666/93, o fundamento da requisição de certidões negativas de recuperação judicial e extrajudicial residia no artigo 31, inciso II, que previa a possibilidade de se exigir certidão negativa de falência ou **concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Na medida em que o instituto da concordata foi extinto e cedeu lugar à recuperação judicial e extrajudicial pelas modificações trazidas na Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, admitiu-se em procedimentos licitatórios a exigência de certidões negativas de recuperação judicial e extrajudicial como requisito de qualificação econômico-financeira e a nossa jurisprudência construiu o entendimento que permitiu a participação e de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que demonstrassem planos de recuperação homologados e em pleno vigor, resultando na edição da súmula nº 50⁷.

Ocorre que a Lei 14.133/21, em seu artigo 69, inciso II, apenas prevê a possibilidade de se exigir certidão negativa de **feitos sobre falência**, nada dispondo sobre os institutos jurídicos da recuperação judicial e extrajudicial.

Reporto-me à linha de interpretação que adotei ao examinar a questão da exigência de atestados de capacidade técnica para fornecimento de bens para expor que, a meu ver, o *caput* do artigo 69 da Lei 14133/21, ao dispor que “A *habilitação econômico-financeira* [...] será **restrita** à ***apresentação da seguinte documentação***”, definitivamente encerra qualquer possibilidade de se adotar interpretação extensiva do inciso II do referido dispositivo legal.

⁷ **SÚMULA Nº 50** - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

Acrescento que a possibilidade de requisição de **relação dos compromissos assumidos pelo licitante** que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, prevista no §3º do artigo 69 da Lei 14.133/21, não reúne condições para ser admitida como autorização implícita ou indireta para a exigência de prova de acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial das licitantes.

Pelo exposto, deverá a Administração limitar-se a exigir, como requisito de habilitação econômico-financeira, apenas e tão somente a documentação prevista no artigo 69 da Lei 14.133/21, a exemplo do decidido nos autos dos TCs 9860.989.24-3⁸ e 23613.989.23-5⁹, ambos de minha Relatoria, além do TC 14092.989.24-3¹⁰, de Relatoria do Eminentíssimo Conselheiro Sidney Beraldo.

2.8. A queixa contra a ausência de critérios objetivos para o exame de amostras é procedente, conforme inclusive reconhece a Administração, que informou em suas razões de defesa que reconheceu a pertinência de impugnação semelhante apresentada na esfera administrativa.

A Administração faz menção ao §3º do artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/21 para sinalizar a pretensão de examinar amostras com a finalidade de objetivamente comprovar a aderência da proposta às especificações definidas no termo de Referência.

A questão dispensa maiores considerações.

Incontrovertida a omissão do edital na definição dos critérios de análise de amostras, ratifico a procedência da impugnação, ciente da pretensão da Administração em dar observância ao artigo 17, §3º da NLLC.

⁸ Tribunal Pleno – sessão de 12/06/2024 – Acórdão publicado no DOE de 21/06/2024

⁹ Tribunal Pleno – sessão de 06/03/2024 – Acórdão publicado no DOE de 15/03/2024

¹⁰ Tribunal Pleno – sessão de 14/08/2024 – Acórdão publicado no DOE de 17/08/2024

2.9. A Municipalidade igualmente reconhece a omissão do ato convocatório quanto a definição de critério de atualização monetária ou compensação financeira ao fornecedor na hipótese de eventual atraso nos pagamentos devidos pela Administração, em desatenção ao comando do artigo 25, caput c/c o artigo 92, inciso V, da Lei federal nº 14.133/21.

Mais uma questão, portanto, incontroversa, cabendo apenas confirmar a procedência da queixa e determinar que a omissão seja corrigida na próxima versão do ato convocatório.

2.10. Quanto à queixa que incide sobre a admissibilidade de impugnações ao edital exclusivamente por meio de plataforma digital, a Municipalidade externou a pretensão de acrescentar na próxima versão do ato convocatório a opção de impugnação também no modo físico.

Embora não possam ser descartados os benefícios decorrentes da pretensão administrativa em ampliar os meios para apresentação de impugnações ao procedimento licitatório, inclusive com inspiração em precedentes de nossa jurisprudência, pondero que, em pregões **eletrônicos** regidos pela Lei Federal nº 14.133/21 a recepção de impugnações exclusivamente por **meio eletrônico** não configura ilegalidade.

Vejam, Senhores Conselheiros, que o Representante reclamou da aceitabilidade das impugnações apenas eletronicamente, mas não se opôs à forma eletrônica do pregão.

Não podemos deixar de considerar que o §2º do artigo 17 da Lei nº 14.133/21 dispõe que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica.

Além disso, **a lei autoriza expressamente** no §4º do mesmo dispositivo legal **que, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a**

Administração determine, como condição de validade e eficácia, **que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico**.

Portanto, sem embargo de recepcionar a decisão discricionária da Municipalidade em ampliar os meios de recepção de impugnações ao edital, a regra do §4º do artigo 17 da Lei Federal nº 14.13/21 não me deixa outra solução que não seja considerar **improcedente** a impugnação do Representante neste ponto.

2.11. Por fim, a insurgência que contesta a apresentação, pela vencedora, de Certificado ou Alvará Sanitário que comprove, conforme aplicável, que a empresa armazenadora e/ou distribuidora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente é **improcedente**, visto que a requisição editalícia conta com o amparo do artigo 66 da Lei federal nº 14.133/21.

Como bem sustentou a Representada em suas razões de defesa, *“trata-se de condição necessária e obrigatória a qualquer empresa do ramo alimentício”*.

O mesmo se pode dizer com relação à reclamação contra a requisição de Certificado de Vistoria Sanitária dos veículos que transportam alimentos. A reclamação não prospera.

O voto que proferi nos autos do TC 015869.989.23-6, acolhido por este Plenário na sessão de 20/09/2023, admitiu a possibilidade de exigência de certificado da vigilância sanitária de veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios e que a referida documentação não incorre em ônus desarrazoado às empresas varejistas e demais fornecedores que tenham seus veículos em condição regular.

2.12. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento na norma do §3º do artigo 171 da Lei 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 189/2024 e do edital respectivo.

Caso venha a lançar nova licitação para a aquisição deste objeto, deverá a Municipalidade, além de se abster do uso da sistemática do registro de preços, promover as seguintes medidas saneadoras:

- 1)** Excluir a exigência de Ficha Técnica dos produtos, emitida pelo fabricante ou produtor;
- 2)** Elaborar novo orçamento com observância rigorosa ao comando do artigo 18, §1º, inciso VI e artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/21;
- 3)** Excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e de Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente como requisito de habilitação econômico-financeira;
- 4)** Dispor sobre os critérios objetivos para o exame de amostras, com atenção ao §3º do artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/21 e ao princípio do julgamento objetivo;
- 5)** Definir critério de atualização monetária ou compensação financeira ao fornecedor na hipótese de eventual atraso nos pagamentos devidos pela Administração, na forma do artigo 25, caput c/c o artigo 92, inciso V, da Lei federal nº 14.133/21;

Proponho **RECOMENDAÇÃO** para que a Municipalidade aprimore a observância à legislação vigente quanto à estruturação e

funcionamento da primeira e segunda linhas de defesa do controle de contratações, especialmente em relação ao controle prévio de legalidade a cargo do órgão de assessoramento jurídico da Administração, disciplinado nos artigos 53 e 169 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

Após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro